

0003721-34.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... CRIMINAL - Recurso da Defesa - Tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas - Inadmissibilidade - Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico - Tráfico bem caracterizado pelas provas dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003721-34.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003721-34.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - DB1378-1/2022 - 1º

Distrito Policial de Americana, DB1378-1/2022 - 1º Distrito Policial de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Glaucio Fernandes dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

GLAUCIO FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (20 microtubos contendo cocaína, totalizando 5,4g de massa líquida; 04 porções de maconha, pesando 22,4g; e 12 pedras de "crack", produto derivado da cocaína, revelando peso de 2,9g), que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 104/105, foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fls. 174/175). O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 165/166).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 180/181).

Em seus memoriais (fls. 187/190), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

A Doutora Defensora do réu (fls. 193/206), requereu a absolvição por falta de provas relativa ao trafico.

Ante a apresentação de matéria preliminar, os autos retornaram ao Ministério Público para manifestação (fls. 215).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, "proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida; 'coisas achadas ou obtidas por meios criminosos' (art. 240, § 1º, b, do CPP); 'instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos' (art. 240, § 1º, c, do CPP); 'armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso' (art. 240, § 1º, d, do CPP); 'objetos necessários à prova de infração ou à defesa do autuado' (art. 240, § 1º, e, do CPP); 'cartas, abertas ou não, destinadas ao autuado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato' (art. 240, § 1º, f, do CPP); e 'qualquer elemento de convicção' (art. 240, § 1º, h, do CPP)".

A alegação de nulidade por ausência de justa causa para a revista não deve prosperar no presente caso. Conforme delimitado nos autos do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), pelo Superior Tribunal de Justiça, a busca deve ser, "baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência", o que resta presente, posto que os policiais verificaram o réu efetuando duas vezes, pelo menos, atos de mercancia, com a entrega de algo para motoristas que ali momentaneamente paravam.

No mais, a fundada suspeita, considerando, também, que o local é conhecido pelo tráfico, restou comprovada pela apreensão de drogas, as quais estavam escondidas nas vestes do réu, além de uma quantia em dinheiro, cuja procedência não restou, minimamente, comprovada nos autos.

Desta forma, a conduta dos policiais restou fundada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa, não se tratando de medida ilegal e abusiva.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 77/76.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína (inclusive na forma derivada - CRAK), de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitiva.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos.

"O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol.

Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º grau de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regridam.

A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável."

E ainda:

"A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do

nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória". (S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

No mais, não há dúvida que a droga "cannabis sativa", popularmente conhecida por "maconha" causa grave dano à incolumidade pública.

Nesse sentido, o editorial do jornal Folha de São Paulo do dia 21 de fevereiro de 2000:

MACONHA E DEPENDÊNCIA

Observa-se, em São Paulo, um aumento no número de casos de pessoas que procuram ajuda médica devido a complicações relacionadas à maconha. Trata-se de uma tendência ainda não quantificada em termos científicos, mas algumas clínicas registraram um acréscimo de 20% na demanda por esse atendimento. A Universidade Federal de São Paulo inaugurou, há três semanas, um ambulatório para esses pacientes. A maconha ainda está longe de constituir um problema de saúde pública, pelo menos um problema tão grande como os 10% de dependentes de álcool na população ou os inúmeros viciados em cocaína e crack. Isso, obviamente, não é razão para fechar os olhos para a questão.

Esse fenômeno com a maconha se explica, em parte, devido a uma mudança de paradigma na psiquiatria. Até meados dos anos 80, a dependência em relação a uma droga era avaliada basicamente pela tolerância (a necessidade de usar cada vez mais para obter o mesmo efeito) e pelo nível dos sintomas de abstinência (os efeitos físicos desagradáveis provocados pela retirada da droga). Em 87, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu incluir também critérios psicossociais que indicassem um envolvimento sério do indivíduo com a substância para determinar se ele era ou não um dependente. Trocando em miúdos, pode ser considerado dependente todo aquele cujo envolvimento com alguma droga lhe provoca problemas sociais. Essa nova visão faz mais sentido. Afinal, o ser humano carrega em sua herança genética ou cultural uma fabulosa capacidade de ligar-se de forma patológica a determinados comportamentos, com ou sem drogas. É o caso, por exemplo, dos jogadores compulsivos. Aí, o próprio cérebro pode estar produzindo substâncias que o levam ao vício. São os chamados opióides endógenos. A literatura médica também registra episódios de dependências mais exóticas, como a de comer cenouras. Não se sabe ao certo se o beta-caroteno encontrado nesse vegetal tem potencial aditivo ou se o vício teria explicação em ritualizações. De todo modo, para a imensa maioria das pessoas, a cenoura é apenas um alimento, e saudável. Tudo está na forma como o indivíduo se relaciona com a droga, que pode ser patológica ou não, dependendo de inúmeras variáveis relacionadas à própria substância e à personalidade do usuário. O fato é que não faz mais tanto sentido falar em drogas leves. Droga é droga e muitas vezes tem consequências desastrosas. (os grifos são meus).

A autoria é indubitável.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-

se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os policiais militares Pedro e Gabriel informaram que se encontravam em patrulhamento, sendo que na rua dos fatos, a uma quadra de distancia, visualizaram o réu, em situação característica de trafico, ou seja, entregando e recebendo objetos, de um veículo e uma motocicleta. Narraram que solicitaram apoio e efetuaram a abordagem do réu, que já se encontrava sentado na calçada. Em revista, foi encontrada uma quantia em dinheiro em suas mãos. Com a chegada da equipe de apoio, localizaram, dentro da calça do réu, um volume, tratando-se de duas meias, onde estavam guardadas as substancias entorpecentes (cocaína, maconha e crack). Declararam, também, que o réu resistiu a prisão, e incitava populares de uma barbearia dizendo "estão me introjando", razão pela qual dirigiram-se a Delegacia. Indagado, o réu alegou ser usuário. Por fim, informaram que o local é conhecido como ponto de tráfico.

E, o policial militar Ivan, disse que foi chamado para fazer apoio a abordagem do réu, e chegando no local o presenciou resistir a prisão. Informou que os demais policiais já haviam localizado a quantia em dinheiro na posse do réu, e que notaram um volume em sua cintura. Indagado, o réu alegou serem drogas, sendo usuário. Efetuada a busca pessoal, localizaram duas meias, onde foram encontradas as porções de substancia entorpecente. Narrou que no momento em que localizaram as meias, o réu começou a incitar a população contra os policiais, dizendo que o estavam "introjando". Por fim, informou que o local é conhecido como ponto de tráfico.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da

narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP - pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - (...) - Depoimentos dos policiais com pequena contradição referente ao papel do apelante no tráfico que não afeta a decisão condenatória - Testemunhas de defesa que apresentaram declarações com detalhes sequer mencionados pelo apelante, em seu interrogatório - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0004594-74.2014.8.26.0161; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos" (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem

desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a juízo para perseguir sistematicamente pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes. (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - 18.08.94)

A forma de acondicionamento do tóxico apreendido evidencia a destinação de tráfico.

Ainda que se considere pequena a quantidade que o réu portava, já ficou patente que os “patrões” do tráfico costumam utilizar-se de pequenos traficantes para a venda. Confira-se à respeito, a matéria do Jornal “O Liberal” de Americana, no dia 21 de

junho de 2009:

MICROTRAFICANTES VIRAM O PRINCIPAL FOCO

DA POLÍCIA - Os microtraficantes, como são chamadas pela polícia as pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas, são o novo foco dos investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). "Esse tipo de traficante é como erva daninha. Quanto mais se prende, mais surge. Por isso temos de combatê-los. Queremos chegar no 'patrão' que está no topo e na base da pirâmide do tráfico", disse o delegado Marco Antonio Pozzetti, titular da DISE. Na semana passada, cinco microtraficantes foram presos. Esta forma de comércio foi criada pelos 'patrões' do tráfico para não sofrerem grandes baixas quando a polícia age. Cada micro fica no ponto de venda, conhecido como 'biqueira', com no máximo 20 unidades de entorpecentes (pedrinhas de crack, papелotes de cocaína e pequenos embrulhos de maconha). Eles são abastecidos pelos 'gatos' como os 'patrões' identificam os distribuidores.

"Os investigadores estão saindo às ruas à procura dos microtraficantes. Na quinta-feira, por exemplo, prendemos um que vendia drogas sentado em um sofá na calçada de sua casa, no Jardim Guanabara. Com ele nós encontramos seis pedrinhas de crack, dois pedacinhos de maconha e mais R\$ 30,00. É o exemplo do microtraficante. Ele estava com uma quantidade reduzida". Disse o delegado da DISE. "O surgimento dos microtraficantes é uma forma criada pelos 'patrões do tráfico para evitar grandes tombos. Prendemos muitas pessoas e a quantidade de entorpecente apreendida é pequena. Assim, a 'biqueira' não sofre prejuízo", contou o delegado.

Uso próprio

As pessoas que são presas também tentam se beneficiar do artifício da pequena quantidade. Eles procuram provar, na Justiça, que o entorpecente é para uso. Assim, tentam 'quebrar' a prisão de tráfico para uso de entorpecente. "A maioria alega que estava com aqueles papелotes ou pedrinhas par consumo próprio", afirmou um dos investigadores da DISE. Pozzetti instruiu os policiais a agirem nas duas pontas da pirâmide do tráfico. "Os micros estão na base e fazendo prisões. Nós conseguimos enfraquecer e até chegar aos donos do comércio", comentou. Os policiais aproveitam as prisões para fazer um mapeamento do esquema do tráfico em Americana. "Nós já sabemos, por exemplo, quem são os responsáveis pelas principais biqueiras. São informações que surgem com as prisões desses microtraficantes", disse o policial. O perfil do vendedor de pequenas quantidades de droga é diversificado, conforme avaliam os policiais da DISE. São adolescentes, jovens e até crianças. Um número cada vez maior de mulheres tem atuado nas 'biqueirinhas' como costuma chamar o delegado. (...) Em Americana, as prisões aconteceram no Jardim Guanabara, Vila Bela, Parque da Liberdade, São Roque, São Jerônimo e na Praia Azul. (...) "O Jardim Guanabara, em Americana, por exemplo, aparece como uma das áreas de grande concentração de pequenos pontos de venda de drogas e vamos intensificar nosso trabalho" afirmou Pozzetti.

Cumprе destacar que o local onde o réu foi preso é conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas.

O acusado Glaucо negou a prática do delito, alegando que a droga apreendida não era sua. Disse, ainda, que cerca de três semanas atrás foi abordado e agredido pelos mesmos policiais, e discutiu com eles, sendo então perseguido.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

Relativo a alegada coação (perseguição e ameaça por parte dos policiais), restou improvada. E, como é sabido, o ônus de provar incumbe a quem faz a alegação.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO CONDENATÓRIO - VIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS - PROVA FIRME E CONSISTENTE DEMONSTRANDO A GUARDA DO ENTORPECENTE PELO RÉU - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA DEFESA - RECURSO PROVIDO - DE OFÍCIO - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE

DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.

- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como autor do crime de tráfico de drogas, imperiosa a reforma da sentença para condená-lo.
- Para a caracterização do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime de ação múltipla, basta que o agente guarde drogas, não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.
- Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
- Impossível a absolvição do agente que alega ter praticado conduta antijurídica sob coação moral irresistível se não comprovada a alegada excludente de culpabilidade, sendo certo que, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus incumbirá à Defesa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.13.083392-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 22/01/2019)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas (maconha e cocaína. Policiais civis, depois de informados por um usuário de drogas acerca da guarda de entorpecentes pelo réu na própria casa, identificaram o imóvel do increpado, foram atendidos por ele e, em busca domiciliar, encontraram sobre a cama um pacote contendo cocaína (970,3g) e diversas porções de maconha (628,6g), cigarros, além de uma balança de precisão e diversos saquinhos plásticos vazios, ocasião em que o réu confessou informalmente o tráfico de drogas e revelou que tinha por função fracionar o entorpecente, o qual pertencia ao traficante Bruno. Testemunhas de defesa que não esclareceram os fatos. Apelante, silente na fase policial, asseverou em juízo que guardara o entorpecente porque fora ameaçado de morte pelo traficante proprietário da droga, alegando, pois, coação moral irresistível. Defesa não se desincumbiu do ônus da prova da excludente de culpabilidade. Negativa e versão judiciais isoladas nos autos. Condenação mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1511522-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/02/2021; Data de Registro: 27/02/2021)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Crack e maconha. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Apreensão de relevante quantidade de entorpecentes na casa do réu, que confessou em Juízo guardá-los em favor de terceiro. Coação moral irresistível não configurada. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Base que deve ser fixada no mínimo. Subsequente incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Suficiência dos requisitos explícitos no dispositivo. Comprovada a primariedade e os bons antecedentes é descabido negar o desconto de penas proporcionado pelo dispositivo em questão apenas presumindo a dedicação do acusado às atividades ou grupos criminosos. Causa de diminuição de pena reconhecida. Regime fechado mantido. Provimento parcial do recurso. (TJSP; Apelação Criminal 0005229-87.2016.8.26.0451; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017)

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e

harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a extrema nocividade da cocaína (inclusive na forma derivada - "CRACK"), exigindo especial rigor no combate ao seu tráfico, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pela necessidade de impor ao traficante pena de severidade correspondente ao elevado risco que o comércio dessa nefanda substância acarreta à saúde pública.

O réu agiu reprovadamente com vontade livre e consciente, dirigida à prática de condutas que representam tráfico de cocaína, droga especialmente perigosa, colocando em grave perigo a saúde pública, acrescendo como circunstância a quantidade expressiva da droga, tendo como motivo o propósito de locupletamento, vale dizer, ganho fácil e espúrio.

Com efeito, segundo Damásio:

"O novo sistema penal prevê duas fases na aplicação da pena. Num primeiro momento, com fundamento no princípio da pena retributiva, fixa sua qualidade e quantidade, elaborando um juízo sobre o passado (juízo de culpabilidade), atendendo à gravidade objetiva do delito, antecedentes e personalidade do agente, sua conduta social anterior, motivos determinantes do fato e suas conseqüências." (Damásio Evangelista de Jesus, "Direito Penal", Parte Geral, 1 volume, 19ª Edição, Saraiva, 1995, p. 509)

Havendo uma graduação de penas, é evidente que a pena mínima, deve ser aplicada, por exemplo, àqueles que comercializam pequena quantidade de "maconha", tóxico muito menos grave e nocivo que a cocaína, que envolve interesses de grupos

altamente perigosos, que para a sua difusão e fabricação se organizam freqüentemente em quadrilhas, patrocinando "chacinas", segundo diariamente noticiado nos jornais. Destarte é indiscutível que a cocaína apresenta um perigo muito maior, uma maior potencialidade de dano social. Como dito acima, a cocaína freqüentemente leva à morte, além de ser porta para outros tipos de tóxicos mais graves, como a heroína, por exemplo.

A propósito, julgando feito em trâmite por este juízo, assim decidiu a Egrégia 11ª Câmara Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo relator foi o Desembargador Di Rissio Barbosa, do seguinte teor:

Comércio Clandestino de entorpecente. Pena. Exacerbação decorrente da natureza da droga, "crack", cujos efeitos são mais graves que outras drogas. Não é só admissível a exacerbação, como também recomendável por diferenciar situações díspares. (Apelação 455.718.3/1-00, 8 de junho de 2005).

Da brilhante decisão, destaco o seguinte trecho:

"...o aumento decorrente do tipo de droga, de extrema consequência, foi adoção que todos os Magistrados deveriam ter em mente ao calcular a pena; realmente, não se pode deferir a mesma repressão aos que se envolvem com drogas consideradas leves, pelas consequências que determinam, e outras consideradas pesadas, aqui com maior desprezo ao infeliz semelhante usuário".

Além disso, existe o imperativo legal do artigo 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual a quantidade e natureza da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal no momento de fixação da pena base. Segundo o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1,956 KG DE COCAÍNA. LEGALIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que "[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]" (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos está suficientemente fundamentada, pois as vetoriais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 1,956 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta e seis gramas) de "cocaína". 3. O quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e elevada quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. MODIFICAÇÃO DE REGIME. PLEITO PREJUDICADO, ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. ADEMAIS, PENA SUPERIOR A 7 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cediço que, quanto à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da variedade/quantidade das drogas

(48,759kg de cocaína e 1,011kg de crack), fundamentos idôneos para majorar a pena-base e recrudescer o regime prisional. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 505.140/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Assim sendo, e somando-se a existência de maus antecedentes, exaspero a apena em 1/5 (um quinto) e fixo a pena em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pela certidão de fls. 129/144.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11343/2006, tendo vista que o dispositivo é inaplicável ao réu reincidente, ex vi legis.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. Uma porque o réu é reincidente, o que impossibilita a adoção de regime mais brando, segundo a jurisprudência:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência específica. Regime fechado. Tratando-se de réu reincidente específico, posto que agora condenado a pena de cinco anos de reclusão, outro não há de ser regime prisional de cumprimento inicial que o fechado. (TJSP; Apelação Criminal 0001074-91.2017.8.26.0617; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 08/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - Recurso da Defesa - Tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas - Inadmissibilidade - Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico - Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos - Regime prisional mais brando - Inadmissibilidade - Acertado o regime prisional fechado para o réu, não se podendo olvidar que se trata de acusado reincidente, merecendo tratamento penal mais severo - (...) - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500257-28.2018.8.26.0613; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Além disso, nos termos do entendimento da jurisprudência (TJSP, 993.07.126969-7, 6ª Câmara, Rel. Des. MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, j. 25.02.201), de acordo com a Lei nº. 11.464, de 28 de março de 2007, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise do eventual preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão. Se assim não fosse, não teria sentido algum outro regime a ser fixado. O legislador, ao tratar o traficante de drogas equiparado a hediondo, negou-lhe vários benefícios que a outras espécies de criminosos seriam cabíveis, como fiança, indulto, sursis, liberdade provisória etc. Assim, não faria sentido que, condenados, esses infratores recebessem pena alternativa ou cumprissem as reprimendas em regime diverso ao fechado.

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO, AINDA QUE EM SUA MODALIDADE "PRIVILEGIADA". REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1) A determinação de cumprimento da pena em regime inicial fechado, para condenados por tráfico de drogas, decorre de exigência expressa na Lei de Crimes Hediondos e na Lei nº 11.343/06. Decisões permissivas dotadas de efeitos "inter partes", não se registrando declaração de inconstitucionalidade "erga omnes" dos indicados dispositivos - Precedente do C. STJ - Maior rigor na repressão de crimes desse jaez, nos termos da CF/88. Compatibilidade, de qualquer forma, com a gravidade concreta dos fatos. 2) Substituição da corporal por restritivas de direitos - Impossibilidade - Circunstâncias concretas a indicar a insuficiência da imposição de pena restritiva de direitos - Art. 44, III, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 0009095-78.2015.8.26.0309; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016)

Assim também se posicionou a 7ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"No tocante ao regime prisional, deve prevalecer o fechado, por força de expressa previsão legal e o montante das penas carcerárias inviabiliza eventual substituição por restritivas de direitos. Afinal, os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade ordeira". (Relator Des. Roberto Mortari, j. 22.05.2014).

O réu não pode apelar em liberdade por vedação expressa contida no artigo 44 da Lei 11.343/2006.

Além disso, o delito de tráfico de entorpecentes é considerado como crime hediondo nos termos da Lei 8.072/90. A gravidade do delito não autoriza a concessão do benefício. O entendimento jurisprudencial não é diverso:
Habeas Corpus - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória proferida em 01/10/2019 - Impetração pleiteando a concessão do direito de apelar em liberdade - Impossibilidade - Custódia cautelar suficientemente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) - Embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida, o paciente registra maus antecedentes e é reincidente específico - Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a futura aplicação da lei penal - Ademais, não há sentido em que o réu, que permaneceu preso durante toda a fase instrutória, seja solto quando da prolação da sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade - Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2283715-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

"Associação para a prática de tráfico de entorpecente (art. 14 da lei n 6.368/76) - condenação judicial - Recusa do benefício de apelar em liberdade - Inexistência de constrangimento ilegal - Irrelevância de inaplicável à espécie a regra do art. 35 da Lei 6.368/76, que proíbe o apelo em liberdade tão-só nos casos de condenação pelos delitos dos arts. 12 e 13. O benefício de apelar em liberdade pode ser validamente recusado a quem sofrer condenação penal pela prática do delito de associação criminosa, tipificado no art. 14 da Lei 6.368/76. A extrema gravidade objetiva desse fato e as